

1500175-47.2022.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Dozinetti de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS.

Trata-se de ação penal deflagrada para apurar a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, praticado, em tese, por Fabio Dozinetti de Oliveira.

É o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, . - Jardim Universitário

CEP: 13600-970 - Araras - SP

Telefone: 19-35442463 - E-mail: ararascr@tjsp.jus.br

1500175-47.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500175-47.2022.8.26.0551

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Dozinetti de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

VISTOS.

Trata-se de ação penal deflagrada para apurar a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, praticado, em tese, por Fabio Dozinetti de Oliveira.

É o relatório. DECIDO.

É o caso de trancamento da ação penal.

Com efeito, em que pese ser possível que guardas municipais, como qualquer cidadão, realizem prisões em flagrante (art. 301, do CPP), por não ostentarem atribuições de investigação ou patrulhamento ostensivo, funções típicas das Polícias Civil e Militar, tenho como nula a prisão feita nestes e, como consequência, as provas dela decorrentes.

Nesse sentido, prisões feitas por guardas civis devem ser restritas àquelas em que exista a certeza visível do cometimento do delito, sendo-lhes vedada atividades investigativas em especial quando baseadas em "denúncias anônimas" e com revistas em possíveis, tal qual ocorreu "in casu".

No presente caso, é da denúncia e dos depoimentos colhidos na fase de investigação que os guardas, extrapolando suas atribuições, ainda que de boa-fé, receberam delação apócrifa sobre a prática de tráfico com a indicação do local e com as características do suposto criminoso e passaram a realizar patrulhamento ostensivo e investigativo, logrando encontrar o réu em via pública.

E mais, com base exclusivamente na denúncia recebida, o abordaram e fizeram revista pessoal, encontrando em seu poder as drogas apreendidas.

Assim sendo, resta evidente que não o flagrante em atitude típica de comercialização de drogas, o que impede que realizem prisão flagrancial.

Em verdade, como se vê, os guardas civis municipais exerceram função típica de polícia ostensiva, incumbida constitucionalmente à Polícia Militar (e neste caso, também e inicialmente, houve trabalho investigativo, cabível à Polícia Civil).

Ora, assim, em verdadeiro trabalho de policiamento ostensivo e investigativo, em atuação típica da polícia militar e/ou civil, os guardas municipais detiveram o réu.

Se o réu tivesse sido visto pelos guardas municipais em franca atitude de traficância, nenhuma mácula haveria na abordagem e prisão feita pelos guardas. Entretanto, não é essa a situação dos autos.

Os guardas realizaram patrulhamento ostensivo e atividade investigativa para desvendar o suposto autor do crime informado por delator anônimo, funções que escapam da esfera de atribuição da Guarda Municipal (art. 144, §8º, da CF/88).

Lembre-se que o princípio da estrita legalidade determina que o agente público só pode fazer o que estiver expressamente previsto em lei. Assim, no caso concreto, os guardas municipais não estavam autorizados a investigar um crime, quanto menos da forma como fizeram neste caso, sem terem visto ou presenciado qualquer atitude criminosa do réu, em verdadeiro combate ostensivo ao crime.

Nesse sentido:

"(...) Investigação e prisão em flagrante em função típica de policiamento ostensivo, iniciada por ação típica de Polícia Judiciária, por Guardas Civis Municipais. Função típica reservada constitucionalmente à Polícia Militar e/ou à Polícia Civil. Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal. Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Relaxado o flagrante, em liminar, confirmada Nulidade processual ab ovo a ser reconhecida. Trancamento da ação penal, de ofício, como consequência." (TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2277974-66.2021.8.26.0000)

"Apelação Criminal. Condenação pelo artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Preliminar acolhida. Prova ilícita. Guarda Municipal. Denúncia anônima. Busca domiciliar. Investigação criminal. Patrulhamento ostensivo e realização de busca e

apreensão não é função da Guarda Civil Municipal. Inexistência de situação de flagrância. Ilegalidade da prova. Inteligência do artigo 144, §8º, da Constituição Federal. Guarda civil municipal está destinada à proteção de bens, serviços e instalações do Município. Absolvição por insuficiência probatória. Apelo parcialmente provido". (TJSP, Apelação Criminal nº 1502753-49.2019.8.26.0272)

"Crimes de estelionato e corrupção de menores - Reformatio in melius com base no artigo 617 do Código de Processo Penal - Precedentes desta 12ª Câmara de Direito Criminal e do Superior Tribunal de Justiça - Abordagem realizada em função típica de policiamento ostensivo por guardas civis municipais e em verdadeira atividade investigativa, funções típicas reservadas constitucionalmente à Polícia Militar e à Polícia Civil Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil Prova ilícita Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO". (TJSP, Apelação Criminal nº 0002166-05.2017.8.26.0068)

Não fosse isso suficiente para anulação das provas existentes, de se ressaltar ainda outro aspecto que torna viciada a prisão dos autos, qual seja, a revista pessoal sem a existência de fundada suspeita.

Nesse sentido, os Tribunais Superiores têm reiteradamente deliberado pela nulidade de abordagens arbitrárias, a esmo ou com base no famigerado "tirocínio policial", com base em "nervosismo" ou situações análogas.

De igual forma, têm decidido que mera "denúncia anônima" não configura "suspeita" com força necessária para autorizar revista pessoal, ainda mais por quem não tem função policial como atividade primordial (conforme já fundamentado acima).

Nesse ponto, destaca-se o que foi decidido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 158.580 acerca da ilicitude de provas em caso semelhante. Vejamos:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE ATITUDE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxe do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de

determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos independentemente da quantidade após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. (...) 16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.).

Daí conclui-se que, seja por terem os guardas municipais agido fora de suas funções, exercendo verdadeiras atividades de investigação e patrulhamento ostensivo, ou mesmo porque ausente justa causa (fundada suspeita) para terem abordado e feito revista pessoal no denunciado, a prisão em flagrante deve ser declarada nula, com a consequente anulação das provas anexadas aos autos com o auto de prisão em flagrante ou dela decorrentes.

Ausentes indícios juridicamente válidos de autoria e materialidade, a ação penal merece o trancamento.

Ante o exposto, nos moldes da fundamentação, determino o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL por falta de justa causa, em razão da nulidade da prisão em flagrante e ilicitude da prova obtida.

Expeça-se o necessário.

Determino a destruição dos entorpecentes apreendidos, bem assim daqueles armazenados para fins de contraprova. Determino a devolução dos valores apreendidos. Oficie-se. Arbitro os honorários ao defensor dativo no máximo permitido nesta fase processual.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, providenciando-se as comunicações de praxe.

P.R.I.C.

Araras, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA